

החלטת מיסוי 28/08

תחום החלטת המיסוי: מיסוי שוק ההון

הנושא: פיצוי אגב הנפקת זכויות - החלטת מיסוי בהסכם

העובדות:

1. בכוונת חברה ציבורית תושבת ישראל, אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב, לבצע גיוס הון בדרך של הנפקת זכויות, לפי תשקיף, לבעלי מניותיה (להלן: **"הנפקת הזכויות"**).
2. בין בעלי מניותיה של החברה ישנם בעלי מניות תושבי ארה"ב, המחזיקים יחדיו מעל 10% מההון המונפק של החברה בניכוי בעלי מניות המחזיקים 10% ומעלה מהון מניות החברה (להלן: **"בעלי המניות האמריקאים"**). מתוך בעלי המניות האמריקאים קיימים בעלי מניות תושבי ארה"ב בלבד, שאינם תושבי ישראל לצרכי מס (להלן: **"בעלי המניות תושבי ארה"ב"**).
3. לאור החזקת בעלי המניות האמריקאיים כאמור לעיל, הנפקת הזכויות תחייב את החברה לפרסם תשקיף בארה"ב. זאת, משום שהפטורים הרלבנטיים מפרסום תשקיף בארה"ב לא חלים בנסיבות דנן. יצוין, כי פרסום תשקיף בארה"ב יחייב את החברה לעמוד בחובות דיווח לרשות ניירות הערך האמריקאית (ה-SEC) בארה"ב.
4. בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז – 2007 (להלן: **"תקנות ני"ע"**) נקבע כי תאגיד מדווח רשאי, בהצעה בדרך של זכויות שבשלה אמור לחול על התאגיד המדווח, נוסף על תקנות ני"ע, גם דין מדינת חוץ, שלא להציע את הזכויות למחזיקי ניירות הערך שהינם תושבי חוץ שבשלם חל על ההצעה דין מדינת חוץ (להלן: **"החרגת בעלי המניות"**), והכול בכפוף לתנאים שנקבעו בתקנות ני"ע.
5. בין יתר התנאים בתקנות ני"ע נקבע, כי עם הנפקת הזכויות לניצעים או בסמוך לאחר מכן, התאגיד יפצה את בעלי המניות תושבי החוץ בפיצוי אחיד והוגן בשל אי הענקת הזכויות (להלן: **"הפיצוי"**) אשר ייתמך בחוות דעת של מעריך שווי חיצוני (להלן: **"השווי ההוגן"**).
6. בכוונת החברה להחריג את בעלי המניות האמריקאים מהנפקת הזכויות במסגרת התשקיף האמור לעיל, ולשלם להם פיצוי לפי השווי ההוגן כאמור. סכום הפיצוי – כולו או חלקו, יכוסה גם באמצעות הנפקת זכויות בגין בעלי המניות האמריקאים לרכז הנפקת הזכויות (להלן: **"רכז ההנפקה"**), אשר יהא חייב למוכרן בבורסה בהתאם להוראות התשקיף במסגרת יום המסחר של שאר הזכויות המונפקות (להלן: **"הפיצוי הבסיסי"**). במידה וייווצר הפרש בין סכום הפיצוי לבין סכום הפיצוי הבסיסי, הרי שהפרש זה ישולם ע"י החברה לבעלי המניות האמריקאים באמצעות רכז ההנפקה וחברי הבורסה, או ישירות על-ידי החברה ככל שעסקינן בבעלי מניות רשומים אמריקאים (להלן: **"התוספת לפיצוי הבסיסי"**). יצוין כי תשלום הפיצוי כולו יבוצע במסגרת הליך ההנפקה.
7. בהתאם לכללי החשבונאות החלים על החברה, הפיצוי יירשם בספרי החברה כקישון מהפרמיה הצפויה להתקבל כתוצאה מהקצאת הזכויות ומימושן.

פרטי הבקשה:

קביעת הסדר המס ושיעור ניכוי המס במקור שיחול על החברה בגין תשלום הפיצוי לבעלי המניות תושבי ארה"ב אגב הנפקת הזכויות, כאמור לעיל.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. נקבע כי מכירת הזכויות בבורסה בישראל על ידי רכז ההנפקה בגין החזקת בעלי המניות תושבי ארה"ב תיחשב כמכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה לניירות ערך בידי תושב חוץ ויחולו עליה הוראות פקודת מס הכנסה והתקנות מכוחה. והכול בהתקיים כל התנאים שלהלן:
 - 1.1. הנפקת הזכויות לרכז ההנפקה הינה בגין בעלי המניות האמריקאים בלבד, אלא אם רכז ההנפקה מחזיק עוד קודם להנפקת הזכויות מניות החברה עבור בעלי מניות אחרים ו/או עבורו (בתיק נוסטרו).
 - 1.2. הנפקת הזכויות לרכז ההנפקה כאמור לעיל בוצעה בשל החרגת בעלי המניות האמריקאים מהנפקת הזכויות במסגרת התשקיף ולמען תשלום הפיצוי בלבד.
 - 1.3. כפוף לאמור לעיל, לא הונפקו לרכז ההנפקה זכויות נוספות מעבר לאלו שהונפקו בגין בעלי המניות האמריקאים.
 - 1.4. כל הזכויות נמכרו ע"י רכז ההנפקה, במסגרת מסחר הזכויות בבורסה לני"ע בישראל.
 - 1.5. התמורה בגין מכירת הזכויות בגין בעלי המניות תושבי ארה"ב הועברה במלואה לבעלי המניות תושבי ארה"ב ישירות ע"י רכז ההנפקה ו/או באמצעות חבר בורסה ו/או באמצעות מסלקת הבורסה. הובהר כי לא ייראו בהעברת התמורה כאמור, באמצעות החברה, לבעלי המניות הרשומים תושבי ארה"ב, כהפרת תנאי זה.
 - 1.6. הוצגו לחברי הבורסה ולחברה (לגבי בעלי המניות הרשומים תושבי ארה"ב) טופסי 2402 חתומים ע"י בעלי המניות תושבי ארה"ב על היותם תושבי חוץ ועל זכאותם לפטור.
2. נקבע כי החברה ו/או רכז ההנפקה ו/או חבר הבורסה ו/או מסלקת הבורסה, לפי העניין, יהיו פטורים מניכוי מס במקור בגין תשלום התמורה ממכירת הזכויות, אשר הוראות סעיף 1 דלעיל חלו לגביהן, לבעלי המניות תושבי ארה"ב.
3. נקבע כי מכירת זכויות, אשר לא התקיימו לגביהן כל התנאים האמורים לעיל, תהא חייבת במס המקסימלי החל בגין רווח הון בישראל. החברה (בגין בעלי מניות רשומים) ו/או חברי הבורסה, לפי העניין, ינכו מס במקור מהתמורה בגין מכירה זו בהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך, במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית), התשס"ג-2002.
4. בנוסף, נקבע כי הוראות סעיפים 3-1 דלעיל יחולו גם על התוספת לפיצוי הבסיסי, לפי העניין, ובלבד שתשלום התוספת האמורה בוצע יחדיו ובאופן זהה לתשלום הפיצוי הבסיסי.
5. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.